



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: RESOL-2019-740-APN-SCI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 8 de Noviembre de 20

Referencia: EX-2017-24238097- -APN-DDYME#MP - OPI 300

VISTO el Expediente N° EX-2017-24238097- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación traída a consulta se presenta el día 13 de octubre de 2017, consiste en la adquisición por parte de la firma H.B. FULLER COMPANY del CIENTO POR CIENTO (100 %) de las acciones emitidas y en circulación de la firma ASP ROYAL ACQUISITION CORP., que se encontraban en manos de la firma ASP ROYAL HOLDINGS LLC.

Que de acuerdo a lo informado por las partes el cierre de la operación de produjo con fecha 22 de octubre de 2017.

Que las consultantes informaron en oportunidad de solicitar la presente opinión consultiva que atento a que la transacción se ha negociado a nivel global, no existe un monto de la operación asignado a la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que, en tal sentido, las partes indicaron que la REPÚBLICA ARGENTINA representa el CERO COMA VEINTIDOS POR CIENTO (0,22 %) de las ventas totales de los productos de la firma ASP ROYAL ACQUISITION CORP., y la relación antes mencionada arroja un valor de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS (\$ 65.765.700.)

Que en primer término, las partes entienden que la operación no está sujeta a la obligación de notificación obligatoria bajo la Ley N° 25.156, por cuanto se encuentra exenta según los términos de su inciso e) del Artículo 10 de la citada ley, y asimismo fuera del alcance de lo normado en el Artículo 3 de dicha norma, toda vez que la operación no surge efecto en el la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que sin perjuicio de lo esgrimido por las partes a lo largo de sus presentaciones, resulta preciso destacar que con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, y su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018, con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018. Dicha norma introduce numerosas modificaciones al texto de la Ley N° 25.156. Entre ellas, la actualización de los umbrales previstos para las notificaciones de operaciones de concentración económica. Al respecto cabe mencionar que el análisis respecto de las operaciones traídas a consulta debe realizarse al momento en el que éstas deberían o no ser notificadas. Por lo tanto, en las presentes actuaciones en caso de decidir que la operación es notificable, dicha notificación se haría en vigencia de la nueva normativa por lo tanto corresponde tener en consideración los nuevos umbrales previstos en la misma.

Que el monto de la operación y activos transferidos se encuentran por debajo de los montos previstos por el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que, en virtud de ello, la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO emitió el Dictamen de fecha 2 de octubre de 2018, en donde en su apartado III pone de resalto que la operación traída a consulta y los argumentos de las consultantes en pos de justificar la exención de notificación de la operación, fueron realizadas en vigencia de la Ley N° 25.156, y dicho servicio jurídico argumentó que “en los términos de lo prescripto en la reglamentación del artículo 81 de la Ley N° 27.442 por Decreto N° 480/2018, el momento en que nace la obligación de notificar determina la tipología causal y los umbrales cuantitativos de excepción aplicables”, y por ello entendió que no son otros que los establecidos en la Ley N° 25.156 y su reglamentación.

Que, por ello, la citada ex Comisión Nacional realizó un nuevo análisis y concluyó que la operación traída a consulta no conlleva efectos en el mercado nacional, y que de analizarse la cuestión a la luz del Artículo 3° de la Ley N° 25.156, dicha operación no se encontraría sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

Que, dando cumplimiento a lo requerido por el señor Secretario de Comercio Interior, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen complementario de fecha 29 de mayo 2019 correspondiente a la “OPI 300” en el cual recomienda, disponer que la operación traída a consulta consistente en la adquisición por parte de la firma HB FULLER COMPANY del CIENTO POR CIENTO (100 %) de las acciones emitidas y en circulación de la firma ASP ROYAL ACQUISITION CORP., que se encontraban en manos de la firma ASP ROYAL HOLDINGS LLC., no se encontraría sujeta a la obligación de notificación establecida, si se adopta como norma aplicable el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

Que, asimismo, el Señor Vocal de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Don Pablo TERVISAN (M.I. N° 23.471.818) emitió el Dictamen en Disidencia de fecha 2 de julio de 2019 correspondiente a la “OPI 300” recomendando al señor Secretario de Comercio Interior a Liberar o exonerar, por los considerandos expresados, a las sociedades comerciales HB FULLER COMPANY y ASP ROYAL HOLDINGS LLC del cumplimiento de la obligación de notificación de la operación consultada, que se establecía en el Artículo 8° de la abrogada Ley N° 25.156 y; Hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la información proporcionada por las partes, en los

escritos obrantes en el Expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertido.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen de fecha 29 de mayo de 2019 al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido por la Ley N° 25.156, el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, el Artículo 22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019 y la Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Por ello,

SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Hácese saber que la operación traída a consulta por las firmas H.B. FULLER COMPANY y ASP ROYAL HOLDINGS LLC., no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la abrogada Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase el Dictamen de fecha 29 de Mayo de 2019, correspondiente a la “OPI 300”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, que como IF-2019-50236572-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Ignacio Werner
Secretario
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Producción y Trabajo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2019-50236572-APN-CNDC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 29 de Mayo de 20

Referencia: OPI N° 300 - Voto Mayoría Dictamen Complementario

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N° EX-2017-24238097-APN-DDYME#MP caratulado “OPI 300 - H.B. FULLER COMPANY Y ASP ROYAL HOLDINGS LLC S/CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY N° 25.156” del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, e iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del Artículo 8° del Decreto PEN N° 89/2001, reglamentario de la Ley N° 25.156 por parte de las firmas H.B. FULLER COMPANY y ASP ROYAL HOLDINGS LLC.

I. REMISIÓN

1. La operación traída a consulta consiste en la adquisición por parte de H.B. FULLER COMPANY (en adelante “HB FULLER”) del 100% de las acciones emitidas y en circulación de ASP ROYAL ACQUISITION CORP. (en adelante “ROYAL”), que se encontraban en manos de ASP ROYAL HOLDINGS LLC (en adelante “la Vendedora”).
2. De acuerdo a lo informado por las partes el cierre de la operación de produjo con fecha 22 de octubre de 2017.
3. Las consultantes entendieron que la operación sujeta a consulta se encontraría exenta de la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la LDC, debido a que se encontraría fuera del alcance del Artículo 3° de la Ley N° 25.156 ya que no tiene efectos en el país, y por encuadrar, a su vez, en la excepción del inciso e) del Artículo 10° de la misma Ley.
4. Respecto de los sujetos intervinientes y actividad de las partes de la operación traída a consulta y el procedimiento nos remitiremos a los Acápites I y III del Dictamen CNDC N° IF-2018-35133412-APN-CNDC#MP, de fecha 23 de julio de 2018, en honor a la brevedad.
5. Cabe destacar que, en dicho dictamen, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la operación de concentración económica traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

II. PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL DICTADO DEL DICTAMEN CNDC N° IF-2018-35133412-APN-CNDC#MP

6. Con el número de orden 45 del expediente luce vinculado el Dictamen CNDC N° IF-2018-35133412-APN-CNDC#MP elaborado por esta COMISIÓN NACIONAL.

7. Con el número de orden 48 luce vinculado el Dictamen de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS N° IF-2018-49082801-APN-DGAJMP#MPYT de fecha 2 de octubre de 2018, en donde en su apartado III pone de resalto que la operación traída a consulta y los argumentos de las consultantes en pos de justificar la exención de notificación de la operación, fueron realizadas en vigencia de la Ley N° 25.156, aunque esta CNDC interpretó y analizó la operación consultada sobre la aplicabilidad de la Ley N° 27.442.

8. En tal sentido, y sin perjuicio de que esta Comisión Nacional realizó la aclaración de que "...el análisis respecto de las operaciones traídas a consulta debe realizarse al momento en el que estas deberían o no ser notificadas..." y, por ende, luego de realizar el análisis correspondiente, concluyó que "...la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442...", dicho servicio jurídico argumentó que "en los términos de lo prescripto en la reglamentación del artículo 81 de la Ley N° 27.442 por Decreto N° 480/2018, el momento en que nace la obligación de notificar determina la tipología causal y los umbrales cuantitativos de excepción aplicables", y por ello entendió que no son otros que los establecidos en la Ley N° 25.156 y su reglamentación.

9. Finalmente, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS concluyó en su dictamen que "entiende que no resulta viable la suscripción de la medida proyectada, en tanto no contempla circunstancias fácticas y procedimentales determinantes al caso ni reúne los recaudos que la normativa aplicable al caso prescribe. No obstante, no siendo vinculante el presente acto de asesoramiento, queda la suscripción de la medida así proyectada bajo criterio y responsabilidad del Señor Secretario de Comercio, en virtud de su rol de Autoridad de Aplicación del régimen en cuestión".

10. Posteriormente, en el orden 49 del expediente sin pase luce vinculado el Informe de esta CNDC N° IF-2018-50617061-APN-CNDC#MPYT de fecha 9 de octubre de 2018, dirigido al entonces Señor Secretario de Comercio mediante el cual sostuvo y ratificó en su totalidad lo manifestado en su dictamen N° IF-2018-35133412-APN-CNDC#MP.

11. Por último, en el orden 50 luce agregada la providencia N° PV-2019-11773887-APN-SCI#MPYT suscripta por el Señor Secretario de Comercio Interior, de fecha 26 de febrero de 2019, mediante la cual se remitieron las presentes actuaciones a los fines de su adecuación con el marco normativo aplicable al presente, conforme lo dictaminado por el servicio jurídico por medio de su dictamen N° IF-2018-49082801-APN-DGAJMP#MPYT.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA A LA LUZ DE LA LEY N° 25.156.

12. De acuerdo a lo explicado en el apartado precedente, el expediente de referencia fue remitido a esta CNDC a los fines de su adecuación de acuerdo a la interpretación que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS realiza respecto de la lectura de la ultra actividad de la Ley N° 25.156, en su dictamen de fecha 2 de octubre de 2018.

13. Esta Comisión Nacional advierte que sin perjuicio del análisis que a continuación se desarrollará, esta CNDC no se aparta del análisis ya efectuado en su Dictamen N° IF-2018-49082801-APN-DGAJMP#MPYT, sosteniendo y ratificando el mismo en todas sus partes.

14. Respecto de la operación traída a consulta y con el único objetivo de cumplir con el requerimiento efectuado por el Señor Secretario de Comercio Interior en la providencia antes nombrada, se procede a determinar si la operación que consiste en la adquisición por parte de HB FULLER del 100% de las acciones emitidas y en circulación de ROYAL, que se encontraban en manos de la Vendedora, se encontraría exenta de la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la LDC, debido a que, según lo indicado por las partes, se encontraría fuera del alcance del Artículo 3° de la Ley N° 25.156 ya que no tiene efectos en el país, y por encuadrar en la excepción del inciso e) del Artículo 10° de la misma Ley.

15. A lo largo de sus presentaciones las partes han manifestado que sin perjuicio de que HB FULLER cuenta con una subsidiaria indirectamente controlada por ella en la Argentina, la empresa adquirida, es decir ROYAL, es una firma que no tiene subsidiarias ni activos en el país, y que su solo contacto con la República Argentina son las ventas que realiza a nuestro país, a través de distribuidores y un número limitado de ventas directas, es decir exportaciones.

16. En tal sentido, las partes informaron los montos de esas exportaciones para los últimos tres años. Asimismo, los consultantes indicaron que esas ventas representan una participación del 2,2% del mercado local, y que ese porcentaje se mantuvo constante durante los últimos tres años.

17. Por otra parte, respecto de la participación de mercado de la parte compradora, la subsidiaria de HB FULLER en Argentina tiene una participación en el mercado local del 14%.

18. Dicho lo anterior, recordemos que el primer párrafo del Artículo 3º indica que “Quedan sometidas a las disposiciones de esta ley todas las personas físicas o jurídicas públicas o privadas, con o sin fines de lucro que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional”.

19. De este modo, para que el artículo 3 de la Ley N° 25.156 resulte aplicable a las personas que realizan actividades económicas fuera del país, las mismas deben realizar actividades económicas que puedan producir efectos en el mercado nacional.

20. A fines de estimar la probabilidad de ocurrencia de tales efectos, procede considerar la sustancialidad, habitualidad y previsibilidad¹ de ventas de dichas empresas en nuestro país. En este caso, las exportaciones de ROYAL hacia nuestro país. Esto es, si bien las actividades de fabricación o comercialización de ROYAL no son desarrolladas por ella misma (o ninguna entidad vinculada) dentro de nuestro país, sus productos tienen presencia local por cuanto son comercializadores independientes que los importan a tal fin y por ende la operación bajo estudio potencialmente podría producir efectos en el mercado nacional. Ello sucedería si y solo si, dichas importaciones fueran una fuente de abastecimiento relevante para nuestro país, lo que sucede cuando las importaciones son sustanciales, habituales y previsibles.

21. Teniendo en cuenta lo expresado, esta Comisión Nacional considera que dichas exportaciones deben reputarse habituales, atento a que las consultantes manifestaron que se mantuvieron constantes durante los últimos tres años, pero poco sustanciales ya que el porcentaje de participación en el mercado local que representan dichas exportaciones es del 2,2%. Asimismo, y tomando en consideración las participaciones de mercado de la subsidiaria local de HB FULLER y de las exportaciones de ROYAL en nuestro país, la participación de mercado conjunta solo asciende al 16,2%.

22. Por tanto, las importaciones no pueden considerarse sustanciales, con base en su escaso valor, volumen y participación en el consumo doméstico y consecuentemente, la potencialidad de efectos en el mercado nacional referida en el artículo 3º de la Ley N° 25.156 es nula, la Ley N° 25.156 no aplica a las personas extranjeras en cuestión, en lo atinente a cualquier acto relacionado con la comercialización de sus productos en la Argentina.

23. Dicho todo lo anterior, y por las consideraciones efectuadas, esta Comisión Nacional entiende que la operación traída a consulta no conlleva efectos en el mercado nacional. Por tanto, en atención a lo requerido por el Señor Secretario de Comercio Interior se informa que de analizarse la cuestión a la luz del Artículo 3º de la derogada Ley N° 25.156 – ley que esta CNDC interpreta no es aplicable al presente caso- la misma no se encontraría sujeta a la obligación establecida en los parámetros que establecía el también derogado Artículo 8º de la Ley N° 25.156.

IV.CONCLUSIÓN

24. Por ello, y sin perjuicio de lo ya manifestado y aconsejado en su Dictamen N° IF-2018-35133412-

APN-CNDC#MP, de fecha 23 de julio de 2018, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA al sólo efecto de dar cabal cumplimiento a lo requerido por el SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO por la providencia N° PV-2019-11773887-APN-SCI#MPYT, de fecha 26 de febrero de 2019, que recepta la recomendación no vinculante de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, le recomienda disponer que la operación traída a consulta consistente en la adquisición por parte de HB FULLER COMPANY del 100% de las acciones emitidas y en circulación de ASP ROYAL ACQUISITION CORP., que se encontraban en manos de ASP ROYAL HOLDINGS LLC., no se encontraría sujeta a la obligación de notificación establecida, a la luz del derogado Artículo 8° de la Ley N° 25.156, normativa que sería la aplicable según el criterio de la referida DIRECCIÓN GENERAL.

25. Elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO DE LA NACIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que el Vocal - Dr. Pablo Trevisan, suscribirá su voto particular por separado.

1 Opinión Consultiva N° 187 – Dictamen CNDC N° 814 del 29 de julio de 2010.

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

María Fernanda Viegans
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia